

0000081-75.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... de aumento de pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 172/176).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Restaram comprovadas no curso da instrução processual a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao réu.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

2ª Vara

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000081-75.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000081-75.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PEREIRA BORGES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

GUILHERME PEREIRA BORGES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 26 de janeiro de 2022, no lugar indicado na inicial, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Victor Gabriel da Silva, trazia com ele e guardava, durante a pandemia do novo coronavírus, para fins de tráfico, 36,04g de cocaína em pó, individualizados em 68 invólucros, 19,15g de cocaína em pó, individualizados em 36 invólucros, 12,89g de cocaína em pedra, individualizados em 90 invólucros, e 110,41g de maconha, individualizados em 58 invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de corromper o referido adolescente, com ele praticando o crime acima descrito.

Em 27/01/2022 a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 61/63).

Foi determinada a notificação do acusado (fl. 90), que apresentou resposta à acusação às fls. 107/111.

Recebida a denúncia em 13 de abril de 2022, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 112/114).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 157/158).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime

de tráfico, apenas com a majorante do art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, afastando-se a imputação do crime autônomo do art. 244-B do ECA (fls. 162/165). A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública e das causas de aumento de pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 172/176).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Restaram comprovadas no curso da instrução processual a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao réu.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação (fls. 33/36), além do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 154/156.

Quanto à autoria, foi confirmada pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante e pela condução do acusado.

A testemunha policial Fabio Luiz Girardi de Oliveira informou que existiam algumas denúncias via 181 que relatavam a ocorrência do crime de tráfico naquele local. Deslocou-se com seu parceiro até o local e fizeram uma breve campana. Visualizou dois indivíduos numa viela. Verificou que a movimentação era típica do tráfico. Resolveu abordar os indivíduos, que foram identificados como Guilherme e o adolescente Victor. O réu acabou confessando a traficância. Estava com certa quantidade de dinheiro no bolso e as drogas estavam em uma sacola, numa moita próxima a eles. O menor negou dizendo que estava apenas fumando um "baseado". Conduziu os dois para a delegacia. O menor ficava na ponta da viela e, quando os usuários entregavam o dinheiro, ele se dirigia até o réu, que estava mais próximo das drogas, o qual lhe entregava as drogas e o adolescente repassava aos usuários. Dez a quinze minutos de campana. Visualizou uns três usuários. Uma porção das drogas estava na moita e outra sacola estava em outro terreno, menos de dez metros. Tinha crack, cocaína e maconha. Não conhecia o réu antes. A sacola estava a cinco metros de distância do réu. O local é conhecido.

As declarações do policial civil Thiago Gouveia dos Santos foram no mesmo sentido de seu colega de farda, apenas acrescentando que já tinha visto o menor anteriormente no local dos fatos.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva dizendo que só estava fumando no local. Tem passagem por receptação.

Todavia, a versão do acusado não tem como prevalecer, posto que evasiva e dissociada das demais provas acostadas aos autos, restando isolada.

A prova colhida no curso da instrução processual foi convergente e ratificou toda a narrativa feita pelos agentes por ocasião da prisão em flagrante, formando um conjunto probatório suficiente a sustentar o decreto condenatório, de modo que fica afastada a tese absolutória sustentada pela combativa defesa.

O fato de a prova estar alicerçada basicamente em depoimentos de policiais que efetivaram a diligência não lhe retira a credibilidade. Os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas quando não se demonstra qualquer interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa anteriormente desconhecida, como no caso dos autos.

Destarte, entre a versão dos policiais, considerados isentos, pois nada se apurou que indicasse interesse específico deles na incriminação do acusado, e a versão sistematicamente negativa do réu, deve se dar maior credibilidade à primeira.

As circunstâncias do caso, mais precisamente a variedade e a forma de acondicionamento das drogas (maconha e cocaína), permitem inferir o objetivo do comércio espúrio de entorpecente, nos termos dos critérios descritos no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, de forma a tipificar as condutas descritas no artigo 33, caput, da referida lei, nas modalidades de "trazer consigo" e "guardar", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em que pese ter sido variada a quantidade de entorpecentes apreendida, o que poderia vir a caracterizar o envolvimento com atividade criminosa, não há como

extrair de tal circunstância isolada referida conclusão. Assim, à míngua de outros elementos que indiquem que o acusado se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, considerando ser ele primário (fl. 125) e não ostentando maus antecedentes, não vejo como não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.

No entanto, considerando a variedade e quantidade dos entorpecentes, acondicionados em porções individuais a potencializar a venda e a disseminação do uso da droga a grande número de pessoas, prudente que o patamar de diminuição seja fixado aquém do máximo, em 1/2.

Por outro lado, restando comprovada a participação do menor na prática delitiva juntamente com o acusado, deve ser aplicada a causa específica de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, devendo ser afastada a condenação pela prática do crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

A questão é dirimida pelo critério da especialidade (lex specialis derogat generali). Assim, ao trazer um elemento especializante, a causa de aumento da Lei de Drogas deve preponderar em prejuízo da tipificação pelo crime de corrupção de menores, evitando-se assim o bis in idem.

Nesse sentido:

"Tráfico de drogas e corrupção de menores. Art. 33 da Lei Antidrogas e art. 244-B do ECA. Autoria bem firmada por meio do relato dos policiais responsáveis pelo flagrante. Apelante que atuava em conjunto com adolescente. Reenquadramento de fato comprovado (tráfico em concurso com menor de idade), a fim de reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas e afastar a condenação pelo delito de corrupção de menores. Dosimetria. Fração redutora referente ao §4º do art. 33 reduzida para ¼. Regime inicial alterado para o semiaberto. Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Motivos e circunstâncias do crime que indicam a insuficiência da substituição. Art. 44, III, do CP. Recursos providos em parte."(TJSP; Apelação 0000518-80.2016.8.26.0599; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Mor - 2º Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 12/08/2018).

"Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 244-B, da Lei nº 8.069/90. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria do delito de tráfico não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Princípio da especialidade que determina a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, em detrimento do crime de corrupção de menores. Redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 que deve incidir em seu grau máximo. Regime aberto que se mostra mais adequado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO." (TJSP; Apelação 0003303-04.2016.8.26.0635; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018).

Sendo assim, procedo à emendatio libelli nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que o delito fora praticado em 26/01/2022, período em que as restrições de circulação determinadas para controle da pandemia da Covid-19 já se encontravam bastante flexibilizadas e que o estado de calamidade havido em outrora também já havia se dissipado na maior parte do país, deixo de reconhecer a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "j", do CP

Diante de tais considerações, demonstradas a autoria e materialidade delitivas, passa-se à dosimetria da pena de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, em observância ao enunciado do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a circunstância da diversidade das drogas (maconha, cocaína e crack), bem como principalmente a natureza destas últimas, que são entorpecentes com maior

poder lesivo e alta capacidade de causar dependência, justifica a majoração da reprimenda.

Com relação às diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; é primário (fl. 125); poucos elementos foram colhidos acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos são os inerentes ao crime; tampouco as consequências do crime exigem maior reprovação; por último, tratando-se de crime vago, não se cogita de o comportamento da vítima ter contribuído para a prática da infração.

Diante de tais circunstâncias analisadas isoladamente, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, estes fixados em valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, uma vez que não há nos autos elementos suficientes a aferir a real situação econômica do acusado.

Inexistindo atenuantes e agravantes a considerar, mantenho nesta segunda fase a pena aplicada.

Na terceira fase, concorrendo a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos e também a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da mesma lei, utilizo o redutor no patamar já estabelecido de 1/2 e a majorante em 1/6, tornando a pena definitiva em 04 anos de reclusão e 400 dias-multa, no valor anteriormente fixado.

Em razão da quantidade da pena privativa aplicada, de acordo com posição pacificada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal e por Resolução do Senado Federal (Res. 05/2012), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade no crime de tráfico por penas restritivas de direitos.

Ora, se não há mais óbice à substituição da pena, a fortiori, não deve mais ser impositivo o regime inicial fechado para os crimes previstos na Lei de Drogas, afinal, se é possível o mais, que é a substituição da pena privativa de liberdade, deve-se entender viável também o menos, que seria a fixação de regime inicial mais brando que o fechado, sob pena de total ilogismo do sistema.

Assim, deverá o réu cumprir sua pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, sanção esta que fica desde já substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, e por todo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para condenar GUILHERME PEREIRA BORGES como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, substituída esta por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e ao pagamento de 400 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Não havendo justificativa à manutenção da custódia preventiva do réu, uma vez que o regime inicial de sua pena é aberto e a sanção foi substituída por penas restritivas de direitos, revogo a prisão anteriormente decretada e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, conforme legislação estadual vigente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária em desfavor do réu de acordo com o artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III da Constituição Federal;

Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA